

1500444-61.2021.8.26.0118

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: LUIGI MONTEIRO SESTARI

Comarca: Cananéia

Foro: Foro de Cananéia

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... na sociedade e combater o fomento do tráfico ilícito de entorpecente. 2. O artigo 28 da Lei 11343/06, é constitucional, uma vez que o direito à intimidade e da liberdade individual não pode sobrepor-se ao interesse coletivo. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, alega-se que o acórdão recorrido viola o art. 5º, incisos X, da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cananéia

Foro de Cananéia

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Pero Lobo, 75, Cananeia-SP - cep 11990-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500444-61.2021.8.26.0118 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500444-61.2021.8.26.0118

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3064986/2021 - DEL.POL.CANANEIA,
19473913 - DEL.POL.CANANEIA

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

VANESSA PONTES LARA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIGI MONTEIRO SESTARI

Vistos.

Dispensado o relatório (art. 81, § 3º, Lei 9099/95).

O feito encontra-se em ordem. Não há preliminares a dirimir. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato tipificado no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

A materialidade delitiva resultou provada pelo boletim de ocorrência (fls. 4/5) e auto de constatação e laudo definitivo químico-toxicológico (fls. 10 e 12/14), bem como pela prova oral colhida.

Por sua vez, a autoria é certa e as provas dos autos demonstram que ela recai, com efeito, sobre o acusado. O conjunto probatório é seguro e autoriza a condenação.

A testemunha JOSÉ LUCAS MATHEUS TEIXEIRA, ouvida em Juízo, relatou que no dia dos fatos a Polícia Civil solicitou apoio da Polícia Militar para cumprimento de um mandado de prisão em desfavor da acusada Vanessa. Narra que ao adentrarem à residência da acusada, esta disse que possuía drogas consigo para seu uso pessoal.

Relata que as drogas estavam nas vestes de Vanessa. Disse, ainda, que na residência foram encontrados vestígios de que a acusada fazia uso de drogas.

A acusada, revel, não compareceu à solenidade da audiência de instrução, o seu momento na Corte em que poderia apresentar os fatos sob a sua ótica, motivo pelo qual não foi possível realizar seu interrogatório.

No caso, diante do testemunho judicial do policial JOSÉ LUCAS MATHEUS TEIXEIRA, aliado à confissão da ré (fl. 6) na fase extrajudicial, não há dúvidas de que VANESSA PONTES LARA efetivamente estava na posse de duas porções de cocaína e quatro pedras de crack, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, todas para seu uso.

Ademais, não há se falar em inconstitucionalidade do art. 28, da Lei nº 11.343/2006 e atipicidade da conduta, sustentando que a conduta de possuir drogas para consumo próprio consiste em autolesão, não podendo, assim, ser tipificada como crime.

A infração penal prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/2006 tem como sujeito passivo e bem jurídico a saúde pública, e não o próprio indivíduo que consome drogas, não havendo falar, assim, em autolesão.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em controle difuso de constitucionalidade, tem afastado a alegação de inconstitucionalidade da norma, por considerar exatamente ser a saúde pública o objeto jurídico no mencionado artigo 28, verbis:

Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário que impugna acórdão da 1ª Turma Recursal Criminal dos Juizados Especiais da Comarca de Belo Horizonte/MG assim ementado: RECURSO DE APELAÇÃO. ART. 28 DA LEI 11.343/06. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUTONOMIA PRIVADA. AUTOLESÃO. BEM JURÍDICO TUTELADO A SAÚDE PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. 1. A saúde pública é o bem jurídico no artigo 28 da Lei 11.343/06, não podendo a autonomia privada sobrepor-se ao interesse coletivo. Não há que se falar em expansionismo na interpretação da expressão para consumo pessoal, haja vista que os núcleos penais buscam resguardar a saúde pública, evitar a proliferação das drogas na sociedade e combater o fomento do tráfico ilícito de entorpecente. 2. O artigo 28 da Lei 11343/06, é constitucional, uma vez que o direito à intimidade e da liberdade individual não pode sobrepor-se ao interesse coletivo. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, alega-se que o acórdão recorrido viola o art. 5º, incisos X, da Constituição Federal de 1988. A instância precedente determinou o sobrestamento do feito em razão do reconhecimento da repercussão geral concernente ao tema nos autos do RE nº 635.659/SP. Contra referida decisão de inadmissibilidade foi interposto agravo nos próprios autos, que repisa a tese exposta no recurso extraordinário, e refuta os fundamentos da decisão recorrida. Decido. Na caso, verifico que a 1ª Turma Recursal Criminal dos Juizados Especiais da Comarca de Belo Horizonte/MG deu provimento ao recurso ministerial e determinou a regular tramitação do feito, sem receber a denúncia. Por outro lado, o recorrente, menor de 21 anos na data do fato, praticou a suposta conduta delitiva em 18.3.2013, marco inicial da prescrição nos termos do inc. I, art. 111, do CP. Assim, considerando que até o presente momento não ocorreu outro marco interruptivo do lapso prescricional, nos termos do art. 111 do CP e que o recorrente tem direito à redução de referido prazo à metade perfazendo, então, 1 ano (art. 115 do CP c/c art. 30 da Lei nº 11.343/2009), constato que sobreveio a prescrição da pretensão punitiva estatal. Logo, com fulcro no art. 107, inciso IV, do CP, declaro extinta a punibilidade de Filipe Diego dos Santos Monteiro, tendo em vista a superveniência da prescrição da pretensão punitiva e, em consequência, julgo prejudicado o presente recurso pela perda de objeto (RI/STF, art. 21, IX, e Lei n. 8.038/1990, art. 38). Publique-se. Brasília, 18 de março de 2015. Ministro Gilmar Mendes Relator Documento assinado digitalmente (STF - ARE: 830135 MG - MINAS GERAIS 0326851-06.2014.8.13.0024, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 18/03/2015)

Ainda, no dia 19 de agosto de 2015, teve início o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 635659, com repercussão geral, no qual se analisa a constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006.

No entanto, o julgamento ainda não foi concluído e, por tratar-se de análise em

controle difuso de constitucionalidade, em caso de reconhecimento da inconstitucionalidade dispositivo, é necessário que haja suspensão da norma pelo Senado Federal (art. 52, X, CF), caso em que, só então, a decisão vinculará juízes e Tribunais, pois o STF tem afastado a tese da abstrativização do controle difuso. Enquanto não se conclui o julgamento e não seja a norma suspensa pelo Senado, para que surta efeitos erga omnes e vinculante, não há que falar em inconstitucionalidade.

Também não há que falar em aplicação do princípio da insignificância ao presente caso e a consequente atipicidade material da conduta.

Ainda que a quantidade de droga apreendida não seja considerável, trata-se de circunstância que já serve de base para a configuração do crime em comento, caso a droga seja apreendida em grande quantidade, estar-se-ia, provavelmente, diante do crime de tráfico de drogas.

Além disso, pela própria natureza do delito de posse de droga para consumo pessoal - crime de perigo abstrato - e o bem jurídico tutelado (saúde pública) inviável é o acolhimento da tese da insignificância, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06) é de perigo presumido ou abstrato e a pequena quantidade de droga faz parte da própria essência do delito em questão, não lhe sendo aplicável o princípio da insignificância (RHC n. 34.466/DF, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 27/5/2013). 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 620033 MG 2014/0317728-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/04/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2015)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Independentemente da quantidade de drogas apreendidas, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. 3. Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Recurso em habeas corpus não provido. (STJ - RHC: 37094 MG 2013/0118921-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 04/11/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2014)

Portanto, devidamente comprovadas a materialidade e a autoria por meio das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, ou ainda, de causas extintivas da punibilidade, tem-se que a conduta é típica, incidindo, pois, nas sanções cominadas no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Passo à dosimetria da pena (art. 68 do Código Penal).

Na primeira fase, a culpabilidade, grau de reprovabilidade da conduta, é normal à espécie. A análise dos antecedentes deve observar o disposto no art. 5º inciso LVII da CF, ou seja, considera-se como tal a condenação transitada em julgado que não configure reincidência, sempre observando o princípio da não-culpabilidade,

conforme é consagrado pela jurisprudência pátria. Os motivos, por sua vez, não merecem maior reprovação, por serem ínsitos à espécie criminosa. As circunstâncias e as consequências do crime não destoaram do normal. Não há elementos nos autos para se avaliar a conduta social e a personalidade da ré. Por fim, em razão da natureza do crime, não há que falar em comportamento da vítima.

Na segunda fase, há a agravante da reincidência, já que a acusada ostenta condenação pelo art. 33 da Lei de Drogas (0000428-51.2016.8.26.0509), com trânsito em julgado em 17/02/2017, não superado pelo lapso quinquenal depurador. Por outro lado, incide a atenuante da confissão espontânea, ainda que na fase extrajudicial, tendo em vista que a ré confessou integralmente os fatos e sua confissão foi utilizada como fundamento da condenação, aplicando-se o teor da Súmula nº 545 do STJ, compensando-se ambas.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

O preceito secundário da norma penal descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 prevê a possibilidade de o magistrado aplicar as seguintes penas: advertência, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo (incisos I, II e III, do aludido artigo).

Tais penas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como ser substituídas a qualquer tempo, ouvidos o Ministério Público e o defensor (art. 27 da Lei n. 11.343/06).

Segundo Guilherme de Souza Nucci,

(...) a opção do julgador, por uma delas, deve basear-se na culpabilidade (grau de reprovação social merecido) e, por consequência, nos demais critérios previstos no art. 59 do Código Penal. Por outro lado, com fundamento nos mesmos elementos (art. 59, CP), pode o magistrado optar pela aplicação cumulativa de duas das medidas previstas nos incisos I a III do art. 28, caput, ou mesmo das três penalidades em conjunto (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4ª ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 332).

A acusada, a despeito de possuir circunstâncias judiciais favoráveis, é reincidente, de modo que entendo que a medida de advertência, aplicada de forma isolada, não surte o efeito esperado, de maneira que não é suficiente para alcançar a finalidade da norma penal.

Assim, aplico à ré VANESSA PONTES LARA a medida de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, esta pelo prazo de 02 (dois) meses, em entidade a ser indicada pelo Juízo da Execução, preferencialmente aquelas indicadas pelo § 5º, do art. 28 da Lei de Drogas.

Consigno que o descumprimento injustificado da medida imposta sujeitará a condenada ao pagamento de MULTA, já que admoestação verbal a um adulto usuário de drogas é sanção totalmente inócua, tudo na forma do § 6º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Resta inviável a substituição por pena restritiva de direitos (art. 44 do Código Penal) ou aplicação da suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal), eis que a pena aplicada não é classificada como pena privativa de liberdade, não preenchendo, pois, a exigência inserida nos caputs dos artigos 44 e 77 e o disposto no art. 80, todos do Código Penal.

Diante da característica da pena acima aplicada, assiste a ré o direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, resolvo o mérito da ação penal e JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR a acusada VANESSA PONTES LARA, por ter praticado fato tipificado no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, à pena de prestação de serviços à comunidade, esta pelo prazo de 02 (dois) meses.

Condeno a sentenciada também ao pagamento das custas e despesas processuais.

Entretanto, considerando que o sentenciado foi assistido por advogado nomeado nos termos do convênio com a Defensoria Pública, associado às circunstâncias do processo, tudo indica sua insuficiência de recursos para fazer frente a esse débito, motivo pelo qual desde logo lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas nesse parágrafo, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do

convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado:

(1) Determino a destruição das drogas, inclusive amostras guardadas como contraprova, vinculada à prova destes autos, na forma do art. 72 da Lei n. 11343/06;

(2) Caso exista pena de multa, providencie a serventia, observado o disposto no art. 336, caput, do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, manifestando-se o Ministério Público e a Defesa (Cláusula Décima Primeira, § 25 do Termo de Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo – Convênio n. 003/2016). Em seguida, tornem-me conclusos para homologação (art. 538, § 1º, das NSCGJ);

(3) Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral;

(4) Expeça-se a guia de recolhimento definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017;

(5) Lance-se o nome do sentenciado no rol do IRGD;

(6) Ofícios de praxe;

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diligências necessárias.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.

Cananeia, 18 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA